

1501101-40.2019.8.26.0581

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Comarca: São Manuel

Foro: Foro de São Manuel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... ciência de que seu filho praticava o tráfico de drogas e que permaneceu guardando os entorpecentes depois da prisão dele, tanto é que iria entregar as drogas a terceiros para fins de tráfico (art. 28, § 2º, da LD).

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Manuel

Foro de São Manuel

1ª Vara

Rua Ettore Targa, s/nº, São Manuel-SP - cep 18650-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501101-40.2019.8.26.0581 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501101-40.2019.8.26.0581

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2283845/2019 -

Delegacia de Polícia de São Manuel, 7694277 - DEL.SEC.BOTUCATU, 1442/19/200 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 2283845 - DEL.POL.SÃO MANUEL, 1442/19/200 - DEL.POL.SÃO MANUEL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIA FERREIRA CAVALCANTI DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CERES DE OLIVEIRA DANCKWARDT

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 02/04) em face de MÁRCIA FERREIRA CAVALCANTI DE SOUZA, já qualificada nos autos, imputando-lhe o delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (LD), porque, em 29 de setembro de 2019, por volta das 08h30min, na Rua Maria Pedroso Madoglio, n.º 110, área rural, nesta cidade e comarca de São Manuel, a ré supostamente mantinha em depósito 104 (cento e quatro) porções individuais e 03 (três) pedras brutas de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 213,82 gramas, além de 29 (vinte e nove) pinos de cocaína, com peso líquido de 10,72 gramas, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, bem como um aparelho telefônico da marca Samsung. A ré foi presa em flagrante delito (fls. 05/06). A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva (fls. 52/53).

A defesa impetrou habeas corpus cuja liminar foi concedida às fls. 131/139.

Alvará de soltura cumprido em 23/12/2019 (fls. 83/84).

Notificada (fl. 77), a acusada apresentou defesa prévia às fls. 87/94.

Recebida a denúncia em 17/02/2020 (fl. 140).

A ordem de habeas corpus foi definitivamente concedida às fls. 160/164, confirmando a liminar.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fls. 164/165).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, a ré foi interrogada (fls. 202/204).

Em alegações finais, a d. representante do Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia; na dosimetria da pena, postula a fixação da pena-base acima do mínimo legal diante da quantidade e da natureza das drogas, o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da LD e a fixação do regime inicial fechado (fls. 235/242).

A d. defesa, por seu turno, postula a absolvição por ausência de provas de autoria; subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 244/253).

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, qualquer nulidade processual que tenha ensejado prejuízo à ré, passo ao exame do mérito.

Anoto que a materialidade delitiva está comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 05/06); boletim de ocorrência n.º 1442/2019 (fls. 07/09); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); termos de depoimento (fls. 12/15); documentos intermediários (fls. 16/17); laudo de constatação provisório (fls. 24/35); fotografias (fls. 36 e 39/43); relatório final do inquérito policial (fls. 64/66), laudo pericial definitivo (fls. 199/201); laudo pericial - telefone celular (fls. 218/231); bem como pela prova oral colhida

Sobreleva notar que a substância apreendida (cocaína, na forma de sal e de crack) se encontra expressamente prevista na Portaria n.º 344/98 e Resolução n.º 104 da Anvisa, amoldando-se perfeitamente à definição legal de droga (art. 1º, §1º, da LD).

Da mesma forma, a autoria está plenamente demonstrada, pois os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A testemunha FABRÍCIO JOSÉ BATISTA, policial militar, narrou que chegou ao conhecimento dos policiais que, dias atrás, em uma residência de São Manuel, teria havido a prisão um pai e dois filhos por tráfico; que a informação dava conta que ainda havia na casa entorpecentes sob depósito da mãe da família, que em breve iria entregá-las a terceiros; que a denúncia indicava, ainda, que a droga estaria na obra do fundo do quintal, no meio de pedras, areia e tijolos. Declarou que foram até a residência e foram atendidos pela ré, que estava sozinha; que ela disse que não havia drogas no local e franqueou a entrada aos policiais. Relatou que, com auxílio de cão farejador, foram encontradas, no fundo do quintal da residência, no meio de uma pilha de tijolos, duas ou três pedras brutas de crack e mais de cem pinos de cocaína; que a ré estava presente durante os fatos acontecidos, tendo presenciado toda a abordagem dos policiais. Mencionou o policial que, indagada a respeito dos entorpecentes encontrados, a ré negou ter conhecimentos das drogas; que, quando foram conduzir a ré até a delegacia, essa entregou o celular aos policiais, que não tinha tela de bloqueio, possibilitando a visualização de várias mensagens de texto e de áudio enviados pela ré a dois rapazes a respeito da entrega dos entorpecentes, nas quais a ré negociava claramente para quem iria entregar os entorpecentes; demonstrou que não sabia para qual dessas pessoas iria entregá-los. Disse que, mesmo apresentadas tais mensagens à ré, ela continuou negando os fatos aos policiais; que a ré não era conhecida dos meios policiais.

No mesmo sentido, FÁBIO AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA, também policial militar, contou

que no dia dos fatos, ele e o soldado Fabrício receberam a informação de que havia droga escondida no quintal da residência da Márcia, e que um ou dois dias antes, o marido e os filhos dela haviam sido presos por tráfico; que foram até a residência e explicaram para Márcia sobre a denúncia de que havia entorpecentes entre tijolos, areia e pedras da construção; que, de pronto, ela franqueou a entrada; que, iniciadas as buscas com o cão policial, localizaram crack e cocaína debaixo das pedras e da areia, bem como no meio das pilhas de tijolos. Declarou que Márcia afirmou desconhecer que os entorpecentes estavam no local; que, quando foram conduzir a ré até a delegacia, essa entregou o celular aos policiais, desbloqueado e sem senha; que notaram que havia conversas de Whatsapp dela com um tal de "Viola" e um tal de "Ricardo"; que a ré perguntava como iria fazer para entregar a droga, para quem iria entregá-la; que, mesmo após escutar as mensagens junto aos policiais, a ré continuou negando os fatos.

No que concerne às testemunhas de defesa/ informantes, cinco pessoas foram ouvidas em juízo.

O informante CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA, filho da acusada, narrou que a ré não comercializava entorpecentes e nem era participante de nenhuma organização criminosa; assumiu a autoria de todos os entorpecentes, dizendo que sua mãe, ora ré, seria inocente e trabalhadora; detalhou que sua mãe é empregada doméstica, saindo de casa cedo e voltando à noite. Disse que os mesmos entorpecentes foram encontrados no dia de sua prisão, que se deu poucos dias antes dos fatos da denúncia, sendo que tais drogas foram recolocadas pelos policiais no local para incriminar sua mãe. Negou ter pedido à ré para entregar os entorpecentes a alguém. Contou que usava o celular de sua mãe, para acessar o Facebook e, às vezes, para conversar com alguém no Whatsapp.

A testemunha de defesa ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA disse conhecer Márcia desde quando passou a morar no bairro Cohab e que Márcia não tem envolvimento com entorpecentes, pois sempre trabalhou como doméstica. Não soube dizer se o marido e os filhos de Márcia tinham envolvimento com o crime.

A testemunha de defesa MARIA LUIZA RIBEIRO DE JESUS relatou conhecer a ré há três anos; mencionou que ela não tem envolvimento com entorpecentes; que ela trabalhava como diarista e atualmente cuida de idosos; que a ré saía cedo para trabalhar e voltava no final da tarde somente.

A testemunha de defesa ARILDO CHINATO aduziu que conhecia a ré, pois ela trabalhava na casa de sua mãe, fazendo faxina, há cerca de 1 ano e 2 meses; que também conhecia a mãe de Márcia há 11 anos, por ela ser cuidadora de sua mãe. Negou que Márcia tivesse envolvimento com entorpecentes.

A testemunha de defesa KÁTIA BRITTO PELICER DE ALMEIDA narrou que conhecia a ré desde 2017, pois a acusada trabalhou em sua residência como faxineira. Não soube informar se a ré tinha envolvimento com entorpecentes. Disse que, na época em que a acusada foi presa, estava trabalhando em sua residência das 8h às 17h; que tinha confiança na ré, pois era uma ótima funcionária.

A ré, interrogada em sede judicial, negou que a posse dos entorpecentes apreendidos; disse que não tinha conhecimento de que eles estavam escondidos em sua residência. Contou que, quando os policiais chegaram, os recebeu de boa vontade.

Com relação as mensagens em seu celular, a ré declarou que, no sábado, foi trabalhar, quando começaram a ligar em seu celular e mandar mensagens falando que "tinham coisas lá, que foram largadas na sexta-feira do seu filho"; que respondeu que não tinha conhecimento disso, e para essas pessoas irem à em sua residência e pegar o que era deles; que não tinha nada lá e que o que tinha já haviam levado na sexta. Contou que estava com medo e não sabia como resolver a situação, disse para irem lá e pegarem as coisas que eram deles. Relata que quando os policiais solicitaram seu aparelho celular para ver suas mensagens, cedeu sem nenhum problema, alegando que não tinha nada a esconder. Indagada sobre com quem teria trocado mensagens, a ré contou que eram amigos de seu filho.

No entanto, mister reconhecer que a narrativa da acusada, corroborada unicamente pelas testemunhas por ela arroladas e que nada sabiam sobre os fatos, vai de encontro às demais provas produzidas tanto na fase inquisitorial, quanto na fase judicial.

Os depoimentos das testemunhas policiais, dotados de fé pública no exercício de suas funções, foram coerentes e harmônicos entre si e, associados ao laudo pericial do celular da acusada (fls. 218/231), demonstram cabalmente que a ré tinha ciência de que seu filho praticava o tráfico de drogas e que permaneceu guardando os entorpecentes depois da prisão dele, tanto é que iria entregar as drogas a terceiros para fins de tráfico (art. 28, § 2º, da LD).

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF.

Destaco, ainda, que, das conversas de Whatsapp juntadas, extrai-se que Márcia afirmou à pessoa de "Viola", um dia antes do fato, que realmente não sabia que as drogas estavam escondidas pelo seu filho Carlos, mas que um terceiro de nome Altair a havia informado. Portanto, a partir do momento em que a ré tomou conhecimento de que havia entorpecentes na casa e continuou a guardá-los, para posterior entrega a terceiros - seja para Altair ou para "Viola" -, mostra-se inevitável a conclusão de que a acusada se tornou depositária da droga, ainda que por curto período.

Como se vê, a prova é robusta a embasar a condenação, pois incontestemente que a ré praticou o núcleo "manter em depósito" drogas, previsto no art. 33 da LD, tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas para a sua configuração. Evidente também a finalidade de mercancia, já que do conteúdo das conversas acostadas se extrai que os entorpecentes eram destinados à venda.

Não concorrem majorantes e minorantes.

Concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Apesar da variedade das drogas - o que será devidamente valorado na primeira fase da dosimetria -, a ré é primária, de bons antecedentes (conforme certidão de distribuições criminais de fls. 183/184), e não há elementos suficientes nos autos a indicar que ela se dedicava a atividades criminosas em coautoria com seus familiares. O que se extrai do conjunto probatório é que a acusada sabia que o seu filho praticava o tráfico de drogas - o que caracteriza mera convivência - e que, depois que ele foi preso, permaneceu depositária por breve lapso temporal; no entanto, não se pode presumir que a ré se dedicava comumente às atividades ilícitas juntamente com seus familiares.

Assim, incide em favor da acusada a presunção de que ela não se dedica a atividades criminosas, já que não há elementos nos autos que a infirmem. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STF:

(...) A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: "A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena". (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas . 2016. p. 50). E também: "(...) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (...)". (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada . 2009. p. 109). Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização

criminosa. HC 154694 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020).

Destarte, promovo a emendatio libelli, com fulcro no art. 383 do CPP, para que a capitulação do delito conste como a do art. 33, § 4º, da LD.

A fração de diminuição será a de 2/3, por inexistirem circunstâncias que justifiquem a redução em menor patamar.

Ausentes majorantes.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Verifico que, na data dos fatos, a acusada era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que a acusada efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006), identifico que a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. A ré possui bons antecedentes, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 183/184. Não há elementos concretos acerca de sua conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são comuns à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, pois o crime é vago. A natureza dos entorpecentes deve ser valorada negativamente, pois foram apreendidos dois tipos de droga, dentre elas o crack, substância de alto potencial lesivo e com grande poder viciante. Por essa razão, aumento a reprimenda em 1/6.

Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fica mantida a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, concorre a minorante do art. 33, § 4º, da LD. Diminuo a pena em 2/3, consoante fundamentação supra.

Fica Márcia Ferreira Cavalcanti de Souza definitivamente condenada a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

Deixo de proceder à detração (art. 387, § 2º, do CPP), por ser de competência do juízo da execução penal, conforme art. 66, III, c, da Lei das Execuções Penais e a jurisprudência do E. TJSP; outrossim, a acusada respondeu ao processo em liberdade. O regime inicial será o aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, pois não há circunstâncias fáticas concretas que justifiquem a imposição de regime mais gravoso.

Ausentes elementos sobre a condição econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP e art. 43 da Lei n.º 11.343/2006).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP), quais sejam, prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de semana (arts. 43, IV e VI, do CP), a serem especificadas pelo juízo da execução.

Substituída a pena e também em razão do seu quantum, incabível o sursis penal (art. 77, caput e § 3º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para, com fulcro no art. 383 do CPP, para CONDENAR MÁRCIA FERREIRA CAVALCANTI DE SOUZA, já qualificada, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e a 194 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Concedo à ré o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP), pois ausentes circunstâncias que a justifiquem, nos termos do art. 312 do CPP; outrossim, o regime prisional fixado e a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos são incompatíveis com a custódia cautelar. Custas pela ré, ressalvada hipótese de gratuidade processual (art. 804 do CPP). Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (art. 72 da LD). Expeça-se certidão de honorários, caso o patrono da ré tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;
- b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
- c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
- d) expeça-se guia de execução definitiva.

A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado. Sentença registrada eletronicamente.

Publique-se.

Intimem-se.

São Manuel, 27 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA